

1506801-52.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Augusto Ramos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... relação ao crime de tráfico de drogas, observo que basta a adequação da conduta a algum dos tipos previstos no artigo 33 da Lei de Drogas para a configuração do crime de tráfico. Assim, basta a conduta de trazer consigo, como no caso dos autos, para a sua perfeita consumação (crime de mera conduta), aliadas as demais circunstâncias do fato.

Trata-se, ainda, de delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506801-52.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506801-52.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2079050/2020 - 73º Distrito

Policial - Jaçanã, 2580/2020 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS BARROS CABRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Augusto Ramos

Vistos.

MARCOS VINICIUS BARROS CABRAL, qualificado às fls. 22, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal; artigo 180, caput, Código Penal; c.c. artigo 69, Código Penal, porque no dia 24 de março de 2020, às 20:52 horas, em ocasião de calamidade pública, na Rua dos Figos, altura do nº 257, Vila Maria, guardava 66 porções de "maconha", com peso total de 21,1 gramas; 35 porções de "skunk", com peso total de 13,1 gramas; e 15 frascos de vidro contendo "lança-perfume", com 90 mililitros, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, destinadas ao tráfico de drogas.

Consta, ainda, que em data incerta, mas no período entre 29 de agosto de 2019 e 24

de março de 2020, MARCOS VINICIUS BARROS CABRAL recebeu, para proveito próprio, o aparelho celular da marca Apple/Iphone, pertencente à vítima Ednaldo Antonio do Nascimento, sabendo ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 76/77), o réu foi devidamente citado (fls. 157), tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 119/124), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 134).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia e a defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da fixação de regime aberto e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Somente nesta data, em razão deste magistrado ter sido designado para a 1ª Vara do Júri da Capital a partir de janeiro do corrente ano, com grande volume de trabalho, com audiências e plenários de julgamento, além do recebimento de centenas de autos físicos para análise, que estavam paralisados em razão da pandemia.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada face ao auto de flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação (fls. 17/21) e laudo químico-toxicológico (fls. 174/177).

O policial militar Cassio de Cristo Furtado, em Juízo, disse que estavam em patrulhamento e foram acionados para uma ocorrência de desentendimento. Ao chegar no local dos fatos, viram o réu Marcos, que aparentou nervosismo e ensejou a realização de abordagem. Com ele encontraram um estojo com 66 invólucros aparentando ser maconha, 35 aparentando ser skunk e 15 frascos aparentando ser lança-perfume, além de cento e vinte reais. O réu informou que tinha acabado de receber o estojo, que seria destinado à venda. Ele também estava com um celular iPhone e, consultado do IMEI, verificaram que constava como produto de roubo. O réu estava a pé. O fato ocorreu de noite. Quanto ao aparelho, disse que pagou 50 reais. Foi ele, Cassio, que fez a revista.

O policial militar Yago Rodrigues dos Santos Moyses forneceu narrativa semelhante. Acrescentou que não conhecia o acusado.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou o tráfico. Disse que estava passando necessidade, pois tinha um filho de oito meses e um homem lhe prometeu que ganharia dinheiro. Pegou os negócios e, no mesmo momento, os policiais o pegaram. Tinha a quantidade que o policial falou. Iria receber 200 reais no dia para vender as drogas. O celular comprou por 50 reais na favela, mas não sabia que era roubado. Tem 23 anos, tem dois filhos menores, trabalha e nunca havia sido preso anteriormente.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, observo que basta a adequação da conduta a algum dos tipos previstos no artigo 33 da Lei de Drogas para a configuração do crime de tráfico. Assim, basta a conduta de trazer consigo, como no caso dos autos, para a sua perfeita consumação (crime de mera conduta), aliadas as demais circunstâncias do fato.

Trata-se, ainda, de delito de perigo abstrato, pois representa a probabilidade de

dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para sua consumação, não se permitindo ao infrator a prova de que seu comportamento era inofensivo (Guilherme de Souza Nucci, Lei Penais e Processuais Comentadas, 5ª edição, Ed. RT, 2010, pág. 356/356, nota 46 ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Diante de todos os elementos de prova que foram colhidos ao longo da instrução criminal, incontestemente que o acusado trazia consigo as drogas encontradas pelos policiais, o que também é corroborado pela sua confissão em Juízo.

Os policiais foram unânimes quanto a terem visualizado o réu em atitude suspeita e, ao decidirem pela abordagem, o réu correu, porém foi abordado em posse das drogas supracitadas, além de dinheiro.

Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, pois nada há nos autos a indicar que tentaram prejudicar o réu ou que teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra ele.

Também o fato de serem policiais, por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. Releva notar, ainda, por importante, que o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.

Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há motivo para desprezá-lo apenas por se tratar de policiais.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (.) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Ademais, a quantidade e variedade de porções de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, a quantia em dinheiro encontrada, tudo isso aliado ao depoimento harmônico dos policiais, bem como dos laudos juntados aos autos, permite-se concluir, com absoluta certeza, que a destinação do entorpecente era, indubitavelmente, o tráfico e o consumo de terceiros. Nesse diapasão: "para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (artigo 52)" (Lei de Drogas Comentada, Luiz Flávio Gomes, p. 182).

Assim, a autoria é indubitosa conforme amplamente visto acima, devendo o réu ser condenado pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao delito de receptação, diante deste quadro probatório, a versão do acusado de que desconhecia a origem ilícita restou isolada nos autos, sendo que a versão apresentada pelos policiais é coesa e coerente com os demais elementos de prova. Os policiais descreveram que em abordagem ao réu foi encontrado também um celular, o qual foi submetido à pesquisa a partir da numeração de IMEI, sendo constatado se tratar de produto de crime anterior.

Ressalta-se, ainda, que em se tratando de crime patrimonial, a posse da res furtiva pelo réu, segundo iterativa jurisprudência, gera a presunção de sua responsabilidade e inversão do ônus da prova, determinando a ele justificativa convincente para a sua posse. Sobre o assunto, o entendimento do E. Tribunal de

Justiça Paulista:

“(...) decorre, para a defesa, a obrigação de demonstrar uma convincente versão absolutória, o que, aqui, sequer se esboçou fazer. Tem-se, nessa mesma linha, que, em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus probatório, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza absoluta e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório” (Apelação Criminal nº 990.08.017387-1, 15ª Câ. Dir. Criminal, Rel. Des. Pedro Gagliardi, j. em 04.11.2008).

“PROVA - Ônus - Insurgência do réu contra decisão que o condenou como incurso no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal à pena de reclusão, em regime prisional fechado, e multa - Circunstância em que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração - Recurso parcialmente provido” (Apelação nº 1.095.073-5, Rel. Mário Devienne Ferraz, j. em 17.09.2007).

Dessa forma, cabia mesmo ao réu indicar elementos de prova para fundamentar sua alegação de que não sabia que o aparelho celular era produto de crime (delito patrimonial), nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, tarefa da qual não se desincumbiu. Nesse entendimento, julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“Não custa lembrar, ademais, que o ônus probandi cabe a quem alega, consoante o disposto no art. 156 do CPP, não tendo o apelante produzido prova hábil, no sentido de amparar sua versão exculpatória, que, como visto, se encontra em aberto conflito com a realidade probatória” (Apelação Criminal. Nº 990.08.069041-8, Rel. Des. Sérgio Coelho, 9ª Câ. Dir. Criminal, j. em 25.03.2010).

O réu alegou que efetuou a compra do celular iPhone de um “nóia” na favela e que teria pagado R\$ 50,00 (cinquenta reais) pelo aparelho. Como é notório, o celular comprado por esse valor e de pessoa desconhecida certamente é produto de crime, sendo inviável o entendimento de que o réu desconhecia essa circunstância.

Assim, o réu também deve ser condenado pelo crime de receptação simples.

Os crimes foram praticados em concurso material, pois perpetrados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos e em contexto fáticos diversos.

Passo à individualização da pena.

A pena base do crime de tráfico deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em atenção ao disposto tanto no artigo 42 da Lei de Drogas, quanto no artigo 59 do Código Penal. Ainda, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base do crime de receptação no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, quanto à agravante do artigo 61, II, “j” do Código Penal, melhor refletindo a respeito, entendo que não pode ser analisada de forma objetiva, vale dizer, referida agravante não pode ser aplicada para todos os crimes praticados durante a vigência do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Importante considerar que os decretos de calamidade pública editados pelos órgãos competentes tiveram por objetivo principal evitar que os administradores públicos incorressem em punições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, como forma de rápida aquisição de respiradores, medicamentos, testes para detecção do vírus, dentre outros insumos, tudo em razão dos rígidos limites orçamentários estabelecidos pela citada Lei Complementar. Para além disso, outros efeitos da calamidade pública declarada pelo Poder Público, em especial na esfera penal, devem ser analisados com cautela,

sempre analisando o caso concreto, como forma de evitar responsabilização objetiva, o que é vedado no ordenamento jurídico penal pátrio.

Dessa forma, o crime praticado pelo réu deve ser verificado de acordo com o contexto fático, ou seja, o agente criminoso deve, de alguma forma, ter se aproveitado do momento calamitoso para a prática da infração penal.

Nesse sentido:

“Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso revela-se mais provável. Faz-se necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade. Como bem se assevera, quando o crime 'é praticado em uma ocasião calamitosa, é mais fácil sua execução e mais difícil a intervenção oportuna dos membros das forças ou corpos de segurança. A defesa da vítima é debilitada e a impunidade do delinquente também é favorecida, pois é mais custosa sua identificação e detenção'” (Luiz Régis Prado, O injusto penal e a culpabilidade como magnitudes graduáveis, Revista Brasileira de Ciências Criminais | vol. 27 | p. 128 | Jul / 1999 Doutrinas Essenciais de Direito Penal | vol. 3 | p. 825 | Out / 2010 DTR\1999\581).

No caso específico dos autos, não vislumbro a incidência da agravante mencionada pelo órgão acusador, tendo em vista que o delito poderia ter sido praticado, sem qualquer diferença, em momento sem a calamidade pública decretada pelo Poder Público. Não houve qualquer proveito ou maior facilidade pelo réu da situação de pandemia para a prática do crime, de modo que a agravante deve ser afastada.

Ainda na segunda fase da dosimetria, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão com relação ao crime de tráfico, em observância à súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ficando mantida a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Também mantida a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para o crime de receptação, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, com relação ao crime de tráfico, entendo que deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é primário, não ostenta Maus antecedentes criminais (conforme certidão própria) e nem integra qualquer organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, além de a quantidade de drogas apreendida não possuir expressividade suficiente para causar menor redução de pena, motivo pelo qual entendo que a redução deve ser realizada no seu máximo, ou seja, em 2/3, resultando na pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Com relação ao crime de receptação, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, reconhecido o concurso material de crimes, as penas dos delitos devem ser somadas, totalizando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicada e a primariedade do acusado.

Finalmente, o acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois presentes todos os requisitos expressos no artigo 44 e incisos do Código Penal.

E, além do réu ser primário, entendo que a medida é socialmente recomendável (artigo 44, § 3º do Código Penal), tendo em vista que o acusado não se envolveu em delitos semelhantes depois do fato dos autos, nem há prova neste sentido. Quanto à possibilidade de substituição no crime de tráfico, o E. Supremo Tribunal Federal tem decidido pela sua possibilidade:

“Habeas Corpus. Constitucional e penal. Tráfico de entorpecentes. Substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. Possibilidade. A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ de 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que fui relator, DJ de 12.12.10. Ordem concedida” (HC 102.678, Relator Ministro Eros Grau).

Com este entendimento, enfim, prestigia-se o princípio constitucional da individualização da pena. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal): 1) prestação pecuniária na quantia equivalente a um salário mínimo, a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais; 2) prestação de serviços à comunidade, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

O réu poderá recorrer em liberdade para este processo, pois incompatível a prisão cautelar com o regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado MARCOS VINICIUS BARROS CABRAL, por infração ao art. 33, "caput" e § 4º, da Lei 11.343/06, c.c. art. 180, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69, Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, devendo ser cumprida em regime inicial aberto.

Nos termos da fundamentação acima, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (1) prestação pecuniária na quantia equivalente a um salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social e (2) prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da privativa de liberdade.

O réu poderá apelar em liberdade, nos termos da fundamentação acima.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, reservando-se quantidade suficiente para eventual contraprova, até o trânsito em julgado, oficiando-se.

Com fundamento no artigo 63 da Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/2006), declaro o perdimento em favor da União do numerário apreendido nos autos e encontrado em poder do acusado, por constituir produto do crime.

Oportunamente, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA